

1500397-94.2021.8.26.0633

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Paulo Alexandre Rodrigues Coutinho

Comarca: Itanhaém

Foro: Foro de Itanhaém

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 12/07/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

SYMON BEZERRA DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Paulo Alexandre Rodrigues Coutinho

VISTOS...

SYMON BEZERRA DA SILVA, já qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público, valendo-se da atribuição que lhe é conferida pelo artigo 129, inciso I, da Constituição Federal, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itanhaém

Foro de Itanhaém

1ª Vara

Avenida Rui Barbosa, 867, Itanhaém-SP - cep 11740-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500397-94.2021.8.26.0633 - lauda

CONCLUSÃO

Aos 12/07/2022, faço estes autos conclusos ao MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Judicial, Exmo. Sr. Dr. PAULO ALEXANDRE RODRIGUES COUTINHO. Eu, _____, subscrevi.

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500397-94.2021.8.26.0633

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

SYMON BEZERRA DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Paulo Alexandre Rodrigues Coutinho

VISTOS...

SYMON BEZERRA DA SILVA, já qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público, valendo-se da atribuição que lhe é conferida pelo artigo 129, inciso I, da Constituição Federal, como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, pela prática dos fatos delituosos narrados na introital de fls. 01/02, in verbis:

"Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 21 de dezembro de

2021, por volta das 21h20, na Rua Dos Lírios, 150, bairro Magalhães, município de Itanhaém, SYMON BEZERRA DA SILVA, qualificado às fls. 05/06, trazia consigo, para fins de entrega a terceiros, 90 "ependorfs" contendo cocaína, 27 porções de Cannabis sativa L e 60 pedras de crack, fazendo, porém, sem autorização e em desacordo com as normas regulamentares. Segundo consta, o denunciado trazia consigo as drogas acima descritas, dentro de 03 pequenas bolsas pretas, as quais dispensou no chão ao perceber a aproximação de policiais militares, seguindo-se sua prisão em flagrante, quando ainda sentado no final da rua."

Acompanhou a denúncia o auto de prisão em flagrante, no qual, estando em termos, foram juntados, dentre vários outros documentos, termos de declarações, o boletim de ocorrência (fls. 12/14), o auto de constatação preliminar de substância de entorpecente (fl. 15), o auto de exibição e apreensão (fl. 16), a nota de culpa (fl. 39), o relatório final lavrado pela Polícia Judiciária (fls. 81/82) e o laudo pericial de entorpecentes (fls. 105/107).

Por ocasião da audiência de custódia, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva (fls. 64/65). Na sequência, foi acoplado aos autos o mandado de prisão devidamente cumprido (fls. 71/72 e 78/79). Na decisão de fls. 90/91, determinou-se a notificação do réu, para fins de apresentação da defesa prévia, nos termos do artigo 55 da Lei nº 11.343/06.

Impetrada ordem de Habeas Corpus em favor do acusado, às fls. 128/131 a pretensão foi acolhida pela Corte Bandeirante, sendo, em seguida, expedido o alvará de soltura (fls. 132 e 145/148). Às fls. 165/168 houve a apresentação de reposta por intermédio de defensora nomeada. Recebida a denúncia e, não sendo o caso de absolvição sumária, foi designada audiência de instrução e julgamento (fls. 175/177).

Na solenidade, abertos os trabalhos, ressaltou-se que o réu seria interrogado após a inquirição das testemunhas arroladas, seguindo a mesma sistemática do procedimento comum ordinário, sumário e sumaríssimo. Na sequência, inquiridos os policiais militares arrolados na denúncia, foi interrogado o acusado. Então, rumou o feito para os debates orais, em vista da inexistência de diligências complementares. A acusação, em linhas gerais, propugnou pela integral procedência da denúncia, ao passo que a defesa requereu a absolvição do réu, sob a égide da anêmia de provas.

É o breve relato dos autos (artigo 381, incisos I e II, do Código de Processo Penal). FUNDAMENTO e DECIDO.

Trata-se de ação penal manejada pelo Ministério Público com o fito de obter a condenação do acusado Symon Bezerra da Silva nas sanções do crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06.

PRELIMINARMENTE:

Da inépcia da denúncia:

Alega a defesa em sua resposta escrita ser a denúncia inepta, em decorrência da forma genérica com que os fatos nela foram narrados. Sem razão, contudo. É que, nos termos do art. 41 do Código de Processo Penal:

"a denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas".

E, na hipótese dos autos, é o que se verifica, na medida em que declinou ela as

circunstâncias de tempo e local em que os fatos ocorreram. Mais seria desnecessário. Preliminar que vai afastada.

Da realização do exame de dependência toxicológica:

Embora o quanto alegado pela defesa nesse particular, observo que o Julgador não está obrigado a determinar a realização do exame de dependência toxicológica se outros elementos de convicção vêm a justificar sua dispensa. O próprio Supremo Tribunal Federal assim tem assentado:

“cabe à autoridade judiciária avaliar necessidade de realização do exame pericial de dependência toxicológica, quando o réu é comprovadamente viciado ou quando há indícios desta condição, não constituindo cerceamento de defesa o indeferimento devidamente justificado” (HC 78.440/9-RJ).

Vale dizer, o simples fato de o réu ter alegado, quando de sua oitiva, ser usuário de drogas, não impõe a obrigatoriedade de realização do exame referido (STJ; HC 47293; J. em 19.12.05). E, no caso dos autos, durante a presente solenidade, o réu demonstrou clareza de raciocínio e higidez mental.

NO MÉRITO:

A materialidade da narcotraficância encontra-se sobejamente evidenciada por intermédio do auto de constatação prévia de entorpecente (fl. 15), do auto de exibição e apreensão (fls. 16) e, principalmente, por meio do laudo toxicológico n. 235.398/2019 de fls. 105/107, oportunidade em que concluíram os experts tratarem-se as substâncias apreendidas de crack (10,1g, divididos em 60 porções), maconha (67,3g, distribuídos em 27 porções) cocaína (14,6g, distribuídos em 90 porções). A autoria do acusado, da mesma forma, malgrado o louvável esforço da defesa, resuma igualmente caracterizada pela prova testemunhal produzida.

Quando de seu interrogatório realizado na fase indiciária (fl. 07), o acusado negou o delito que lhe é imputado. Alegou que havia saído para comprar um maço de cigarros, quando, ao passar pelo local dos fatos, um desconhecido o abordou pedindo cigarro. No momento em que atendeu ao pedido, avistou uma viatura policial, átimo em que o desconhecido saiu correndo, sendo, então, abordado pelos policiais. Os milicianos encontraram no chão duas pequenas bolsas com os entorpecentes, cuja propriedade nega.

Em Juízo salientou que na fatídica data estava num bar para comprar cigarro. Após a aquisição, ao montar em sua bicicleta, foi abordado pela polícia militar. Ninguém viu sua prisão, inclusive o pessoal do bar. Na realidade, os policiais forjaram a situação flagrancial, sem que os conhecesse anteriormente. Veio de Poá para Itanhaém em busca de trabalho, tendo se hospedado na casa de sua avó.

Todavia, quando confrontada a versão externada pelo acusado com as demais provas produzidas, desfalece ante sua fragilidade, evidenciando, sobremaneira, tratar-se de um subterfúgio lançado para elidir os rigores da lei penal.

O policial militar Roberto, em seu depoimento prestado em solo policial (fl. 04) e em Juízo, declarou que na data dos fatos realizava patrulhamento de rotina pelo bairro Jardim Magalhães (lado morro) e, ao adentrarem na rua dos Lírios, viram que no final dela havia um indivíduo sentado. Este, ao visualizar a viatura, jogou no chão uma pequena bolsa preta e empreendeu fuga, correndo para um matagal. Esclareceu o miliciano haver desembarcado da viatura e conseguido acompanhar e deter o réu, posteriormente identificado como Symon Bezerra da Silva. Em revista pessoal, foi encontrado em poder dele uma lanterna, uma carteira com documentos pessoais e uma cédula de dois reais. Na bolsa preta por ele dispensada foram encontrados noventa microtubos contendo cocaína, uma outra bolsa pequena, na cor

azul, com bolinhas brancas, contendo sessenta pequenas pedras de crack, embaladas individualmente em plástico verde, e vinte e sete porções de maconha, embaladas individualmente em plástico verde.

Em juízo, embora tenha mostrado dúvida em relação à cor da bolsa encontrada com o acusado, disse não ter dúvidas que com ele fora encontrada uma lanterna e que trajava ele, na data, uma bota, suja de mato.

Estes, em linhas gerais, foram os mesmos fatos articulados pelo policial militar Danillo, quando em seu depoimento prestado tanto em solo indiciário (fl. 05), bem como na presente solenidade. Indagado por várias vezes, esclareceu ter avistado o momento em que o réu soltou a bolsa preta, local em que posteriormente encontradas as drogas.

É cediço que o valor do depoimento policial, inexistindo má-fé, constitui importante elemento de prova, o qual merece confiança, pois realizado após compromisso e sem contradita da parte do réu. Aliás, sobre a validade dos depoimentos dos policiais, relembre-se que:

"o valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstra - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos" (STF - 1ª Turma - HC 74.608-0/SP - Rel. Min. Celso de Mello - DJU de 11.04.97, pág. 12.189).

Em outras palavras, segundo os milicianos, ao realizarem patrulhamento de rotina pelo local dos fatos, avistaram o acusado. Este, ao perceber a presença policial desfez-se de uma bolsa preta e empreendeu fuga em direção a um matagal, mas logo foi detido. Ao efetuarem a abordagem, localizaram as drogas apreendidas na bolsa preta que o réu havia jogado.

Estas são as provas. Diferentemente do que pretende fazer crer a defesa, entendo assistir razão à acusação na imputação de tráfico que é ofertada ao acusado. É que a quantidade da droga encontrada (60 porções de crack, 27 porções de maconha e 90 porções de cocaína), transparece a finalidade comercial própria do tipo penal.

Observe-se ainda que os entorpecentes apreendidos já se encontravam em pequenas porções, adredemente preparados para venda, e que a abordagem fora realizada após a atitude suspeita esboçada pelo acusado. Veja-se que os depoimentos prestados pelos policiais mostraram-se harmônicos, sendo, ainda, secundados pela apreensão de entorpecentes (crack, maconha e cocaína).

Todo o contexto da situação flagrancial não deixa dúvidas acerca da conduta ilícita cometida pelo acusado. De resto, não se pode imaginar razões que justifiquem a alegação de estarem os policiais a acusar um desconhecido da prática de um delito, quando isso não ocorreu, unicamente para atender a algum sentimento íntimo sádico de culpar terceiros.

Diga-se de passagem, oportuno lembrar que:

"o crime de tráfico de entorpecentes compreende dezoito ações identificadas pelos diversos verbos ou núcleos do tipo, em face do que tal delito se consuma com a prática de qualquer delas, eis que delito de ação múltipla ou misto alternativo" (STJ; HC 27704/MS; Sexta Turma; Min. Rel. Hamilton Carvalhido; J. em 09/05/2006).

E ainda:

“considera-se consumado o tráfico quando evidenciada o estado de flagrância em quaisquer de seus núcleos, ou seja, no momento da importação ou exportação, do depósito ou do transporte, de trazer consigo ou da guarda do entorpecente.” (STJ; HC 34374/MS, Min. Gilson Dipp; Quinta Turma; DJ 01/07/2004).

Em resumo, encontra-se, pois, o acusado incurso nas sanções do art. 33, caput, da Lei 11.343/06.

DOSIMETRIA:

A culpabilidade, entendida como grau de censura contida na ordem jurídica para reprovação da conduta do réu, deve ser considerada normal. O acusado não é possuidor de antecedentes criminais. E isso porque, não havendo condenação definitiva, tal aspecto não poderá ser valorado em seu desfavor, por respeito ao princípio da presunção de inocência, resguardado em âmbito constitucional. Vale dizer:

“(...) inquéritos policiais ou ações penais em andamento, inclusive, sentença condenatória sem o trânsito em julgado, não podem, em razão do princípio constitucional do estado presumido de inocência, ser considerados para agravar a pena-base do condenado” (STJ; HC 92665/RJ; Min. Laurita Vaz; 5ª Turma; J. em 13/08/09).

Nesse sentido, aliás, é a Súmula 444 do STJ.

Sobre a conduta social do acusado e sua personalidade não foram amealhados elementos suficientes nos autos. Os motivos e as circunstâncias são próprios à espécie. As consequências do crime foram normais. O comportamento da vítima em nada contribuiu para o delito.

Diante destas circunstâncias judiciais, aplico a pena-base ao réu em seu mínimo legal, 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, no valor, cada um, de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato, nos termos do artigo 43 da Lei n. 11.343/06.

Ausentes quaisquer agravantes e atenuantes.

Ausentes quaisquer causas de aumento. Presente, por outro lado, a causa de diminuição prevista no §4º do artigo 33 da Lei de Drogas, opero a diminuição em 1/2, considerando a diversidade (cocaína, crack e maconha) da droga, bem como as circunstâncias do caso. A este respeito, observo que:

“o artigo. 42 da Lei n.º 11.343/2006 impõe ao Juiz considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da droga, tanto na fixação da pena-base quanto na aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4.º do artigo 33 da nova Lei de Drogas” (STJ; HC 163495/SP; Rel. Min. Laurita Vaz; DJe 19/10/2011).

Inexistindo outras causas de modificação da pena, torno-a, destarte, em definitivo, em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, no valor, cada um, de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato, nos termos do artigo 43 da Lei n. 11.343/06.

Considerando que o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento acerca da inconstitucionalidade da fixação de regime inicial fechado para cumprimento de pena com base exclusivamente no artigo 2º, parágrafo 1º, da Lei 8.072/1990 (Lei dos Crimes Hediondos), deve o julgador, quando da condenação, ater-se aos parâmetros

previstos no artigo 33 do Código Penal, não podendo fundamentar a fixação do regime inicialmente fechado unicamente em relação à hediondez do delito de tráfico de drogas.

A tese restou assim ementada:

"É inconstitucional a fixação ex lege, com base no artigo 2º, §1º, da Lei 8.072/1990, do regime inicial fechado, devendo o julgador, quando da condenação, ater-se aos parâmetros previstos no artigo 33 do Código Penal." (ARE 935.967 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 15.03.2016)

Desse modo, os critérios para a fixação do regime prisional inicial devem se harmonizar com as garantias constitucionais, sendo necessário exigir-se sempre a fundamentação do regime imposto, ainda que se trate de crime hediondo ou equiparado. Vale ressaltar que tais circunstâncias não elidem a possibilidade de o magistrado, em eventual apreciação das condições subjetivas desfavoráveis, vir a estabelecer regime prisional mais severo, desde que o faça em razão de elementos concretos e individualizados, aptos a demonstrar a necessidade de maior rigor da medida privativa de liberdade do indivíduo, nos termos do §3º, do art. 33, c.c art. 59 do Código Penal.

Na espécie, a pena privativa de liberdade deverá ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, tendo em vista a nocividade e a diversidade da droga apreendida (cocaína e crack), ex vi do art. 33, §2º, 'b', e §3º do mesmo preceito.

A possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por outras restritivas de direito há de ser analisada sob o prisma do art. 44 do Código Penal. Conquanto expressa a vedação acerca da aplicação do instituto aos casos de tráfico, tal qual se depreende dos artigos 33, §4º, e artigo 44, ambos da Lei n. 11.343/06, o Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do Habeas Corpus n. 97256, publicado em 16/12/2010, cujo relator foi o Min. Ayres Brito, em controle difuso de constitucionalidade, concedeu a segurança pretendida para:

"remover o óbice da parte final do art. 44 da Lei 11.343/2006, assim como da expressão análoga 'vedada a conversão em penas restritivas de direitos', constante do § 4º do art. 33 do mesmo diploma legal." E isso por se entender que "o processo de individualização da pena é um caminhar no rumo da personalização da resposta punitiva do Estado, desenvolvendo-se em três momentos individuados e complementares: o legislativo, o judicial e o executivo. Logo, a lei comum não tem a força de subtrair do juiz sentenciante o poder-dever de impor ao delinquente a sanção criminal que a ele, juiz, afigurar-se como expressão de um concreto balanceamento ou de uma empírica ponderação de circunstâncias objetivas com protagonizações subjetivas do fato-tipo. Implicando essa ponderação em concreto a opção jurídico-positiva pela prevalência do razoável sobre o racional; ditada pelo permanente esforço do julgador para conciliar segurança jurídica e justiça material."

Ademais, em 15/02/2012, o Senado Federal, valendo-se da prerrogativa que lhe é dada pelo art. 52, inc. X, da Constituição Federal, editou a Resolução n. 5, suspendendo a execução da expressão "vedada a conversão em penas restritivas de direitos" do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006.

Ainda que a Resolução editada pelo Senado Federal tenha se limitado a suspender a restrição existente somente no §4º do art. 33 da Lei de Drogas, forçosa é a extensão de sua leitura também para a redação dada ao art. 44 do mesmo diploma, quando veda o mesmo benefício. É que o precedente jurisprudencial que motivou a edição da Resolução referida entendeu por inconstitucional tanto a vedação contida no art. §4º do art. 33 como também a do artigo 44, ambos da Lei n. 11.343/06.

No caso dos autos, em vista da primariedade do acusado e do montante de pena privativa de liberdade aplicada, deverá esta ser substituída por duas penas restritivas de direito (art. 44, §2º, do CP), consistentes: i) na prestação de serviços à comunidade, na razão de 01 (uma) hora de tarefa por dia de condenação, conforme o disposto no §3º do art. 46 e; ii) na prestação pecuniária no valor de 01 (um) salário mínimo à entidade pública, nos termos do art. 45, §1º, do CP

Face à substituição da pena privativa de liberdade, incabível se mostra a suspensão de sua execução (art. 77, inc. III, do CP).

DIANTE DO EXPOSTO:

JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA e, em consequência, CONDENO o acusado SYMON BEZERRA DA SILVA, já qualificado, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 02 (DOIS) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO, em regime inicialmente semiaberto, e ao pagamento de 250 (DUZENTOS E CINQUENTA) DIAS-MULTA, no valor, cada um, de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato, nos termos do artigo 43 da Lei n. 11.343/06. Isto por considerá-lo incurso nas sanções do artigo 33, §4º, da Lei n. 11.343/06.

Substituto a pena privativa de liberdade aplicada ao réu por duas penas restritivas de direito (art. 44, §2º, do CP), consistentes: i) na prestação de serviços à comunidade, na razão de 01 (uma) hora de tarefa por dia de condenação, conforme o disposto no §3º do art. 46 e; ii) na prestação pecuniária no valor de 01 (um) salário mínimo à entidade pública, nos termos do art. 45, §1º, do CP

Deixo de condenar o réu em custas processuais, dada a hipossuficiência denotada.

Por ter sido condenado por crime de que se livra solto, em virtude da substituição da pena privativa de liberdade por outras restritivas de direito e, principalmente, por não estarem presentes os requisitos do art. 312 do CPP, poderá o acusado recorrer em liberdade, conforme art. 387, §1º, do mesmo diploma, se por outro não estiver preso.

Deixo de fixar eventual indenização mínima, tal qual consta no art. 387, inc. IV, do CPP, por entender incompatível tal estipêndio com o crime apurado, dada à natureza difusa das vítimas.

Transitada em julgado, tome o cartório as seguintes providências:

1. Comunique-se ao Juízo Eleitoral para as providências cabíveis, tal qual consta do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal;
2. Lance-se o nome do acusado no rol dos culpados, fazendo-se as anotações de estilo, nos termos do artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal;
3. Extraia-se a guia de execução definitiva e encaminhem-se ao Juízo da Execução, conforme artigo 105 da 7.210/84;
4. Desde logo, não havendo interesse em recorrer, sai a parte acusada intimada para pagamento da pena de multa, bem como da taxa judiciária, se houver, no prazo de 10 dias, sob pena de inscrição em dívida ativa (art. 479 das NSCGJ). Recolhida, comunique-se a respeito ao Juízo da Execução; decorrido in albis o prazo ou infrutífera a intimação, extraia-se certidão de sentença para encaminhamento à Procuradoria Geral do Estado, comunicando-se a respeito ao Juízo da Execução, observando-se, para tanto, o art. 482, §1º, das NSCGJ. Havendo interposição recursal, i-se-a quando do trânsito em julgado.

Registre-se. Cumpra-se. Publicada em audiência, saem os presentes intimados.

Itanhaém, 12 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA